

1500410-56.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... vinculada à criminalidade organizada, afastando-se a figura do tráfico privilegiado.

Neste sentido, a Constituição Federal reserva tratamento especialmente severo ao tráfico ilícito de entorpecentes nos artigos 5º, inc. XLIII e LI, e artigo 243, parágrafo único. Assim, a impossibilidade de se aplicar a substituição ao grave crime de tráfico ilícito de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500410-56.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500410-56.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2055974/2022 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 23280617 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 584/22/110 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2055974 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE DIAS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

PAULO HENRIQUE DIAS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado

como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 13h00, na Rua Teotônio vilela, nº 140, Jardim Calux, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, guardava e tinha em depósito, para fins de traficância, drogas consistentes em 1,09kg (massa líquida) de Tetrahidrocannabinol (THC), também conhecida como maconha, acondicionados em 375 invólucros plásticos do tipo "filme"; 87,55g (massa líquida) de cocaína na forma de crack, acondicionados em 585 invólucros plásticos; 136,38g (massa líquida) de cocaína, acondicionados em 250 invólucros plásticos e 373g (massa líquida) de cocaína, acondicionados em 780 microtubos plásticos do tipo "eppendorf", substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão de págs. 13/14, laudo de constatação provisória de págs. 25/28 e laudo de exame químico-toxicológico de págs. 81/83. Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais civis receberam informação anônima de que no local dos fatos havia um indivíduo, qualificado posteriormente como o acusado PAULO HENRIQUE, procurado pela Justiça e que utilizava um imóvel para a guarda de entorpecentes.

Os policiais, então, realizaram diligências até o local e, ao chegarem lá, constataram ser uma habitação coletiva e se depararam com um cômodo que estava com a porta aberta, no qual PAULO HENRIQUE se encontrava deitado e com forte odor de droga.

Assim, realizaram a abordagem e, após vistoria no local, encontraram em poder de PAULO HENRIQUE 375 invólucros de maconha, 585 invólucros de crack, 250 invólucros de cocaína e 780 microtubos de cocaína, além de duas malas, três cadernos com anotações diversas e quatro aparelhos celulares.

PAULO HENRIQUE foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia, onde exerceu seu direito de permanecer em silêncio e somente se manifestar em juízo (pág. 11).

Considerando a elevada quantidade, variedade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, a sua forma de acondicionamento (em embalagens individuais, prontas para a venda e consumo de terceiros), o local onde estavam guardadas (em um imóvel utilizado pelo acusado), assim como a informação anônima recebida pelos policiais civis, não há dúvidas de que as substâncias se destinavam ao comércio ilícito de entorpecentes.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial a págs.04/61. Notificado (pág.119), o acusado ofertou defesa prévia a pag.112/113. Recebida a denúncia às págs. 114/115, o réu foi regularmente citado a pag. 144. Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas comuns e duas testemunhas de defesa, interrogando-se o réu.

Em debates, a acusação requer a condenação do réu nos termos da denúncia, com elevação da pena base, reconhecimento da agravante da reincidência e atenuante da confissão e fixação de regime inicial fechado.

Em memoriais (págs.160/181), a defesa requer a absolvição por ilicitude da prova (invasão inconstitucional de domicílio) ou, ainda, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a fixação da pena base mínima, reconhecimento da atenuante da confissão e regime mais benéfico.

É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do delito de tráfico de

substância entorpecente, não havendo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade do delito vem demonstrada no auto de exibição e apreensão a pág. 13/14 (duas malas de viagem com rodinhas, anotações típicas da contabilidade do tráfico de droga, quatro aparelhos celulares e droga), nos laudos de constatação às págs. 25/28, químico-toxicológico às págs. 81/83 e periciais juntados à págs. 121/122 (anotações contábeis), 123/124 (malas) e 134/136 (aparelhos celulares).

Quanto à autoria, após a opção pelo silêncio na fase policial (pág. 11), em Juízo o acusado ofertou parcial confissão:

Era procurado pela Justiça e precisava de dinheiro para pagar dívida oriunda do uso de droga, no valor de R\$4.000,00 (quatro mil reais). Para quitá-la, aceitou guardar droga em sua casa. Havia duas semanas os traficantes deixavam e retiravam droga de sua residência, situada no local dos fatos. Reside sozinho.

Na data do fato, os policiais arrombaram a porta de sua residência enquanto dormia e ali apreenderam duas malas contendo droga, fechadas com cadeado. Todavia, desconhecia a espécie e quantidade de substância entorpecente armazenada dentro delas. Delas não exalava qualquer odor.

Seu único aparelho celular foi apreendido. Não sabe se, dentro das malas, havia outros aparelhos celulares ou anotações contendo contabilidade típica da mercancia ilícita.

A confissão de guarda e depósito da droga foi ofertada na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias constitucionais. Todavia, a alegação do acusado de que desconhecia a espécie e quantidade de droga guardada em sua residência ficou isolada nos autos pelo mais da prova colhida em instrução.

A prática do delito pelo acusado nos moldes descritos na denúncia vem confirmada, sob o crivo do contraditório, nos depoimentos dos policiais civis André Luiz Nunes Bolonha e Yuri Ferreira Uynne. Em relato coeso e harmônico com o anterior, as testemunhas relataram os passos da diligência encetada na data dos fatos e espancaram qualquer dúvida quanto à autoria:

Receberam denúncia anônima, por telefone, noticiando que indivíduo procurado pela Justiça guardava substância entorpecente na casa dele, tendo sido informando o endereço. O denunciante descreveu rapaz com tatuagens. O imóvel situa-se na comunidade do Jardim Calux, região conhecida por pontos de tráfico de droga. Comunicado, o Delegado de Polícia solicitou à equipe diligência no local.

Dirigiram-se ao local do fato em duas viaturas, sendo uma delas descaracterizada. Tratava-se de habitação coletiva de dois ou três andares. O portão metálico que dava acesso à habitação coletiva estava aberto. Ingressaram no local e, no primeiro andar, sentiram forte odor químico oriundo de determinada residência. A porta estava encostada.

Abriram a porta e depararam-se com o réu deitado em colchão. PAULO HENRIQUE não ofertou resistência. Ao lado do colchão havia duas malas de viagem, com rodinhas. Estavam fechadas com zíper, sem cadeado. Dentro das malas foi encontrada elevada quantidade de porções individuais, prontas para venda, de maconha, cocaína em pó e crack. Também foram apreendidos aparelhos celulares e anotações típicas da contabilidade do tráfico de droga.

O acusado residia naquele cômodo. Havia fogão, panela com comida, roupas do acusado e colchão onde ele estava deitado.

Inquirido, PAULO HENRIQUE admitiu que realizava o tráfico de droga para o próprio

sustento, pois tinha sido demitido de emprego de garçom quando foi descoberto pelo empregador que era procurado pela Justiça pelo crime de roubo.

O acusado não estava sob efeito de droga.

Diante da movimentação verificada na rua depois da prisão do agente, optaram por algemar o acusado por segurança.

Não conheciam o réu antes da abordagem narrada.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 18.10.1996 p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

É certo que as testemunhas não recordaram alguns detalhes da diligência. Ocorre que pequenos esquecimentos ou as contradições apontadas pela defesa em memoriais, em pontos não relevantes, são compreensíveis em razão do tempo decorrido entre os fatos e a oitiva em Juízo, bem como pelo número de diligências das quais os policiais participam.

Ainda nessa quadra, cumpre anotar que se as testemunhas são concordantes no essencial, o que ocorreu no caso em testilha, eventual esquecimento de pontos secundários não é mal, porque reveste os depoimentos de credibilidade.

Se fossem rigorosamente idênticos, ponto por ponto, passariam de imediato a impressão de que oriundos de uma única fonte, artificialmente composta e até fraudulentamente multiplicada (Rel. CORRÊA DE MORAES - RJTACRIM 33/82). Inexiste o mínimo indício de que os policiais tivessem qualquer motivo para colocar em risco as suas carreiras forjando uma situação prejudicial ao réu, que sequer conheciam, imputando-lhe falsamente crime.

Nesta linha: "São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, rel. Osni Pereira, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câmara Criminal, julgado em 27/01/2015).

A não qualificação de civis não é incomum, diante da lei do silêncio que impera nas Comunidades.

Não há exigência de formal expedição de ordem de serviço para atuação de investigadores de polícia, ao contrário do afirmado pela defesa. As diligências podem ser determinadas de vários modos, dentre eles ordem verbal de Delegado de Polícia.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico de droga pelo réu.

Destaca-se que, ao ofertar parcial confissão, afirmando que não tinha conhecimento da espécie e quantidade de droga no interior das malas, o réu buscou em Juízo redução da reprimenda e, principalmente, o afastamento de indícios – presentes justamente pela elevada quantidade de drogas - de que integra criminalidade organizada para a prática da mercancia ilícita.

As malas guardadas em sua residência não estavam trancadas com cadeado e exalavam forte odor químico, sentido do lado de fora do aposento do acusado. Evidentemente, pouca droga não estava acondicionada dentro delas.

Outrossim, não se entrega a indivíduo inexperiente expressiva quantidade de droga, de elevado valor econômico. O acusado, para ter tido acesso a tal quantidade, por óbvio se dedicava à atividade criminosa havia algum tempo, tendo adquirido razoável confiança da criminalidade organizada

Certo é que, além da harmônica prova oral acusatória, a quantidade, natureza e variedade da substância entorpecente apreendida (375 porções de maconha, 585 porções de crack e 1030 porções de cocaína em pó), a forma como acondicionada (individualmente, em malas de viagem, cf. laudo pericial de págs.123/124), a apreensão de anotações típicas da contabilidade da mercancia ilícita (laudo pericial com imagens às págs.121/122) e de diversos aparelhos celulares, além das circunstâncias da prisão, tornam evidente que a droga apreendida se destinava ao consumo de terceiro.

Tais circunstâncias constituem elementos relevantes para a configuração do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal, conforme preconiza o artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06.

Cumprе anotar que a circunstância do réu não ter sido preso no momento em que efetuava a venda da droga que portava, por si só, não afasta a imputação feita na denúncia.

O crime de tráfico, como delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, consoma-se com a ocorrência de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dentre as quais se insere aquela imputada ao acusado na denúncia, não sendo exigível, necessariamente, a prática de atos onerosos, pois suficiente a identificação da finalidade mercantil.

Finalmente, ainda em relação à prova, não se olvida a divergência sobre o ingresso dos policiais no local do fato: Os policiais afirmaram que o portão que dá acesso às casas da habitação coletiva estava aberto, assim como a porta da residência de Paulo Henrique. O acusado aduz que a porta de sua casa estava arrombada (não soube dizer se o portão que permite ingresso às casas estava fechado ou não). Os depoimentos das testemunhas de defesa, arroladas para manifestação sobre este específico ponto, não tiveram o condão de alterar o panorama probatório, francamente incriminador.

A testemunha Davi afirmou que reside perto do local do fato, na 'rua debaixo'. Estava no 'mercadinho do Adão' quando viu um veículo Sandero, de cor prata, parar na frente da habitação coletiva onde mora o réu. Dele desceram indivíduos que para o imóvel ficaram olhando. Um 'cara' entrou e pouco depois ouviu barulho. Em seguida, subiram outros e apenas um permaneceu do lado de fora do imóvel. Minutos depois os indivíduos desceram com Paulo Henrique.

Conhece o acusado 'da tabacaria'.

Embora tenha dito que reside próximo do local dos fatos (chegou a mencionar 'ao lado' e depois 'na rua debaixo'), Davi estranhamente não soube dizer o nome da rua onde fica a habitação coletiva.

A testemunha também afirmou que o portão da habitação coletiva fica permanentemente fechado. Todavia, confrontado sobre tal declaração, já que não reside no local, Davi disse ter sido assim informado por pessoa responsável quando ali procurou cômodo para locação, em data anterior ao fato apurado nos autos (a testemunha não mencionou, inicialmente, em seu depoimento, que os indivíduos arrombaram tal portão, mas que entraram no acesso às residências e, em seguida, ouviu-se um barulho).

Seu depoimento não convenceu o Juízo.

A testemunha Vitor também prestou declarações para apontar arrombamento do portão da habitação coletiva onde residia o acusado.

Disse que se dirigia à sua residência, no horário de almoço, quando visualizou indivíduos descendo de um automóvel prata ou branco, com armas nas mãos (nada neste sentido informou a testemunha Davi), passando a arrombar o portão da habitação coletiva. Saiu correndo e nada mais viu.

Amigo da irmã do réu, ficou evidente a intenção de beneficiar o agente. Não é crível a dinâmica apontada por Vitor, ou seja: Policiais civis descem do carro e, de plano, passam a arrombar portão de local onde várias pessoas moram e em plena via pública, às 13h00. Seria, inclusive, medida 'contraproducente', uma vez que o barulho chamaria atenção do suspeito que procuravam, possibilitando a sua fuga.

Os depoimentos das testemunhas de defesa não se revestiram de credibilidade suficiente para convencer o Juízo acerca de arrombamento de portão de entrada da habitação coletiva e da porta do aposento do réu.

As fotografias juntadas às págs.146/150, por si só, sem prova convincente de que os policiais civis praticaram o arrombamento, não anulam prova obtida com a diligência policial.

Estranha-se, nesse passo, ausência de qualificação de moradores da habitação coletiva, pela defesa, para a confirmação do alegado arrombamento, os quais seriam, evidentemente, os interessados em apontar irregularidade policial.

Fato é que a alegação policial de que o portão de entrada da habitação coletiva estava aberto prevalece nos autos.

E, nessa quadra, não havia necessidade de prévio mandado de busca e apreensão e tampouco há que se falar em nulidade da prova obtida nos autos.

O Supremo Tribunal definiu, em sede de repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, aptas a indicar ocorrência de situação de flagrante delito (RE n.603.616 – Rel.Ministro Gilmar Mendes, DJE 8/10/2010).

Neste sentido o recente voto do Ministro Rogério Schietti Cruz, relator do HC 598.051/SP, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 02/03/2021. No caso destes autos, as fundadas razões (justa causa) estavam presentes.

Os policiais civis receberam denúncia sobre guarda e depósito de substância entorpecente em residência situada no interior de habitação coletiva por indivíduo procurado pela Justiça. Comunicaram o fato à Autoridade Policial, que solicitou diligência no local pela equipe de investigadores. Assim fizeram as testemunhas.

Sobre a diligência decorrente de delação anônima, transcrevo orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal:

“Nada impede, contudo, que o Poder Público, provocado por delação anônima (“disque-

denúncia", por exemplo), adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, "com prudência e discricão", a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da "persecutio criminis", mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas" (HC 100.042/R0, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 8.10.2009).

Como bem destacado pelo Desembargador Relator Camargo Aranha Filho, em Acórdão que analisou o tema (TJSP; Apelação Criminal 1501361-08.2021.8.26.0530; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pontal - 1ª Vara; Data do Julgamento: 31/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022): "Mutatis mutandis, de fato, se não há vedação de ordem constitucional ou legal à notícia anônima de crime, bem como ao incentivo do Poder Público para que a população informe às autoridades os fatos criminosos de que tenham conhecimento, visando, com isso, conferir mais efetividade ao combate à criminalidade, tornar-se-ia um contrassenso encorajar os cidadãos a denunciarem uma atividade delituosa para, depois, infirmar esse elemento de convicção e considerar contaminadas todas as provas subsequentes, ainda que lícitamente produzidas a partir daquela". Quando chegaram no local, o portão de acesso às residências da habitação coletiva estava aberto. Ali os policiais civis ingressaram.

Quanto a esta conduta, não se olvida que a inviolabilidade do domicílio é garantia fundamental de matriz constitucional, tratando-se de cláusula pétrea prevista no art. 5º, XI, da Constituição da República de 1988, segundo o qual "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Ocorre que a habitação coletiva, enquanto aberta (e os policiais disseram que o portão estava aberto. Nesta sentença foi afastada a tese defensiva de arrombamento), por si só, não se insere no conceito 'casa'.

Com efeito, consoante §5º do artigo 150 do Código Penal:

"§ 5º - Não se compreendem na expressão "casa":

I - hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do n.º II do parágrafo anterior".

O domicílio inviolável, na realidade, é o aposento da habitação coletiva.

Preconiza o §4 do artigo 150, do Código Penal:

§ 4º - A expressão "casa" compreende:

(...)

II - Aposento ocupado de habitação coletiva".

Este, sim, só pode ser invadido, se houver fundadas razões (justa causa).

E tal pressuposto está preenchido na hipótese vertente.

Com efeito, os policiais relataram que as residências estavam com as portas fechadas e não havia movimentação de pessoas no local.

Todavia, um aposento no primeiro andar exalava forte cheiro de química, típico da cocaína (afirmação verossímil diante da elevada quantidade de cocaína em pó e na forma de pedra - crack: 1.615). A porta estava aberta, encostada. Ingressaram. Ali surpreenderam o acusado deitado em colchão, ao lado de duas malas de viagem contendo quase 2.000 porções individuais de droga, prontas para venda, sendo 375 invólucros de maconha, 585 invólucros de crack, 1030 de cocaína em pó. As malas não estavam fechadas com cadeado.

Portanto, o contexto fático anterior ao ingresso na residência do acusado (onde elevada quantidade de droga foi apreendida) permitia a conclusão acerca da ocorrência de crime no local, caracterizando concreto quadro de flagrante de crime permanente (tráfico de droga), sendo legítima a ação policial e legal a apreensão das duas mil porções de droga.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DE AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA.(...) É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de

flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas na presença de fundada razão para a ação policial, como ocorre na espécie. Doutrina. Precedentes do STJ e STF..." (STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 0174605-87.2020.8.13.0000 MG 2020/0088140-9. Publicado em 03/06/2020). Lícita a prova obtida com a diligência policial. Por derradeiro, não militam quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes em benefício do réu, ausente prova nesse sentido.

Não se olvida a justificativa ofertada pelo réu ao confessar o seu envolvimento com a mercancia ilícita: Havia contraído dívida oriundo do uso de droga e aceitou armazenar substância entorpecente em sua casa para quitá-la.

Declarou ter iniciado o consumo de substância entorpecente a partir de agosto de 2021, quando se desentendeu com a mãe de seu filho. A prisão do réu ocorreu em fevereiro de 2022

A versão não é verossímil.

De plano, não há prova de que o acusado se dedica ao uso de droga.

E os policiais declararam que o agente não aparentava estar sob efeito de droga durante a sua abordagem. O próprio acusado não fez alegação neste sentido. O réu declarou-se usuário de maconha e cocaína em pó. Preso desde fevereiro p.p, não há nos autos relato de alteração comportamental ou de saúde, quadro que não se coaduna com o de um dependente químico. Outrossim, a defesa não requereu a instauração do incidente de dependência químico-toxicológica e o Juízo não vislumbrou elemento para determinação da diligência de ofício.

E em Juízo o réu ofertou raciocínio coerente, fornecendo, com clareza, detalhes sobre o delito e ação policial. Não se verificou a existência de indício mínimo acerca de comprometimento da incapacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta e/ou determinar-se de acordo com este entendimento.

Outrossim, cediço que traficantes não deixam usuários de droga acumular dívida de R\$4.000,00 e tampouco deixariam à disposição de indivíduo persistente no consumo de tal substância (a ponto de adquirir dívida de razoável valor) quase 2.000 (duas mil) porções individuais de droga, diante do evidente risco de prejuízo econômico.

Ao contrário, para ter acesso a tal quantidade, por óbvio o agente se dedicava havia algum tempo à atividade criminosa, obtendo a confiança da criminalidade organizada (tal critério jurisprudencial encontrável tanto no Col. Supremo Tribunal Federal - RHC 117.867/MG rel. Min. Luiz Fux j. 22.10.2013, quanto no E. STJ (AgRg no AREsp 359.220/MG rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 3.9.2013 e AgRg no AREsp 180.580/MG mesma rel. j. 7.3.2013).

De qualquer forma, ainda que tivesse sido adotada como verdadeira a premissa defensiva (sem respaldo probatório nos autos e não crível), não estaria configurado o estado de necessidade.

Há que se comprovar que a conduta criminosa foi a derradeira para a sobrevivência do agente, sob pena de se acolher a prática criminosa como meio de vida, ainda que para quitação de dívida. Inexiste nos autos, contudo, prova de que o agente agiu para se proteger de perigo atual e inevitável que não tenha dado causa, ônus insculpido no art. 156 do Código de Processo Penal e do qual não se desincumbiu a contento.

O acusado teria condições de encontrar qualquer outra forma lícita para a obtenção para quitação de sua dívida, como a grande maioria da população necessitada, composta por pessoas de bem.

Anote-se inexistência de tese defensiva acerca de coação moral irresistível para a

prática do delito e, nesse contexto, de prova de ameaça insuperável, inelutável, atual, ou seja, uma força a que o coacto não pode subtrair-se ou enfrentar.

Portanto, o acusado realizou conduta típica - artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - antijurídica e, em face de sua culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar nos termos do artigo 68 do Código Penal, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis ao acusado.

O quantum de droga apreendida (1.990 porções de substância entorpecente, fracionadas em 375 invólucros de maconha, 585 invólucros de crack, 250 invólucros de cocaína e 780 microtubos de cocaína), demonstra o devastador resultado que a conduta do increpado provocou no meio social. GRAVE é a consequência do crime, que é de perigo abstrato.

Deve ser destacado que a cocaína, principalmente, em pó ou na forma de pedra (crack), tem alto potencial ofensivo, gerando maior probabilidade de provocar dependência química, de forma a atingir com mais vigor a saúde pública, bem jurídico protegido pelo legislador. Na hipótese dos autos foram apreendidas 1.615 porções de cocaína.

Relevante esclarecer que o Col. Supremo Tribunal Federal, inclusive, exarou o entendimento de que a "natureza" (ou "qualidade") e quantidade do entorpecente destinado à comercialização configura critério hábil para a exasperação da pena dos traficantes ("HC 94655/MS MATO GROSSO DO SUL, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 19/08/2008, Primeira Turma).

O legislador brasileiro, ao instituir a norma do artigo 42, da Lei 11.343/06, impôs aos juízes o dever de ponderar, no momento da fixação das penas dos delitos previstos nessa lei especial, "a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente", e isto com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal".

Saliente-se que a quantidade de droga constitui motivo idôneo para o aumento da pena-base, não sendo considerado elemento intrínseco ao tipo penal, haja vista ter o próprio legislador destacado tais diretrizes no referido artigo 42, da Lei nº 11.343/06, em razão da possibilidade de atingir montante significativo de usuários e colocar ainda em maior risco o bem jurídico tutelado, qual seja a saúde pública. Nesse sentido:

"Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente" (STJ, AgRg no AREsp 1.509.839/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DEJ 18/06/2020).

Não se pode olvidar, outrossim, o lucro total com a venda de cada porção individual de maconha, cocaína e crack, que somaram quase duas mil, que culminaria no alto lucro dos operadores da cadeia do narcotráfico.

Também deve ser destacado que não se entrega a indivíduo inexperiente expressiva quantidade de droga, de elevado valor econômico. O acusado, para ter tido acesso a tal quantidade, por óbvio se dedicava à traficância havia algum tempo, tendo adquirido razoável confiança da criminalidade organizada (tal critério jurisprudencial encontrável tanto no Col. Supremo Tribunal Federal - RHC 117.867/MG rel. Min. Luiz Fux j. 22.10.2013, quanto no E. STJ (AgRg no AREsp 359.220/MG rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 3.9.2013 e AgRg no AREsp 180.580/MG mesma rel. j. 7.3.2013).

Tal circunstância demonstra que não se cuida, na espécie, de apenas um desvio na vida do réu, que na época dos fatos já era procurado pela Justiça por ter se evadido de estabelecimento prisional onde cumpria pena de roubo (cf. mandado de prisão de págs.22/24 e autos DEECRIM nº 00095558-77.2017).

Tais circunstâncias e consequências do delito denotam periculosidade acentuada e diferenciada, bem como conduta social avessas aos preceitos que presidem a convivência em comunidade. Sobressai-se, no fato em tela, maior grau de censurabilidade na conduta do agente, que não se manteve apenas nos moldes inerentes ao tipo penal em espécie, nos exatos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Assim, fixo a pena base do réu acima do mínimo legal. Considerando a quantidade de droga (1.990 porções, sendo 1615 de cocaína na forma de pó ou em pedra- crack - e o restante de maconha), as nefastas consequências que produziu a conduta do agente (crime de perigo abstrato) e as desfavoráveis condições subjetivas do acusado (que praticou o delito após se evadir de estabelecimento prisional. Era procurado pela Justiça), elevo em 1/4 a reprimenda de Paulo Henrique, o que perfaz 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa.

Aumento mínimo ou em fração menor da acima estipulada não atende às finalidades da sanção penal, pois o caso se diferencia dos demais similares, sob pena de inobservância do princípio isonômico e da mais adequada individualização da pena em cada caso concreto.

Reincidente (autos nº 0000470-79.2017 - 5ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Crime de roubo. Trânsito em julgado em 2018. Pena em cumprimento), elevo a pena do acusado em 1/6, fixando-a em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 729 dias-multa.

Não incide a atenuante da confissão espontânea.

O réu foi surpreendido em poder das duas malas contendo elevada quantidade de droga, guardadas dentro de sua residência. Buscou, então, isenção ou redução de sua responsabilidade penal, admitindo parcialmente os fatos narrados na denúncia, afirmando invasão de seu domicílio, dívida com o tráfico e ausência de conhecimento do conteúdo (espécie e quantidade de droga), alegação afastada pelo mais da prova produzida nos autos, conforme fundamentação acima.

Nenhum elemento fornecido pelo acusado em seu interrogatório foi utilizado para dar suporte à fundamentação utilizada nesta sentença condenatória. Seus dizeres não foram relevantes para a formação da convicção judicial, amparada no mais da prova colhida em instrução.

Não incide causa de aumento de pena. Não se aplica a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não preenchidos os predicados legais. O réu é reincidente.

O valor de cada dia-multa será calculado no valor unitário mínimo e atualizado desde a data da infração.

O regime para o início de cumprimento de pena é o fechado. Mostra-se adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade CONCRETA do delito de tráfico, circunstâncias em que foi praticado, suas consequências de desfavoráveis condições subjetivas do acusado, que demonstram a sua periculosidade e ousadia, reclamando reação severa, proporcional e seguramente eficaz, sob pena de impunidade.

Inexiste relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. O acusado guardava e tinha em depósito, ciente de tal fato, expressiva quantidade de droga (1.990 porções individuais, a maior parte de cocaína em pó, além de crack e maconha), pronta para distribuição, o que não se entrega a indivíduo inexperiente. O agente, para ter acesso a tal quantidade, por óbvio já tem que estar envolvido com a criminalidade, dela tendo adquirido razoável confiança.

Tal circunstância demonstra que não se cuida, na espécie, de apenas um desvio na vida do acusado, que na época dos fatos já era procurado pela Justiça por ter se evadido de estabelecimento prisional (cf. mandado de prisão de págs.22/24 e autos DEECRIM nº 00095558-77.2017).

Intensa carga de reprovabilidade social recaiu sobre o acusado, sobretudo por se tratar de um crime de consequências gravíssimas, que provoca a ruína física e

patrimonial de inúmeras pessoas (no caso dos autos, a quantidade de droga torna ainda mais intensa a censurabilidade da conduta do réu), servindo, ainda, como meio propulsor de outros graves delitos. Trata-se, portanto, de um delito de perigo presumido ou abstrato.

O réu apresentou periculosidade acentuada e diferenciada, bem como conduta social avessas aos preceitos que presidem a convivência em comunidade, o que o sujeita à modalidade mais severa.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou aplicação do "sursis", não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. A concessão de tais benesses, ademais, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena e constituiria incentivo à reiteração da conduta.

Note-se que o próprio artigo 44 do Código Penal estipula casos específicos em que não é permitida a substituição da pena, obstando a concessão do beneplácito legal a casos em que a substituição não tem o condão de alcançar os fins colimados com a aplicação da pena e da lei penal.

E neste ponto, a aplicação de uma medida tão branda e complacente vai de encontro ao tratamento austero e rígido que vem expresso pelo ordenamento jurídico brasileiro, principalmente quando se trata, como apurado nos autos, de atividade vinculada à criminalidade organizada, afastando-se a figura do tráfico privilegiado.

Neste sentido, a Constituição Federal reserva tratamento especialmente severo ao tráfico ilícito de entorpecentes nos artigos 5º, inc. XLIII e LI, e artigo 243, parágrafo único. Assim, a impossibilidade de se aplicar a substituição ao grave crime de tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado a hediondo, que tanto assola a comunidade, fica evidente com a interpretação sistêmica do ordenamento jurídico nacional, concluindo-se pela vedação como reflexo esperado ao tratamento mais rigoroso dado pela Constituição da República e pela legislação ordinária ao crime de tráfico de drogas.

Resulta ilógico substituir penas privativas de liberdade para impor sanções restritivas de direitos a condenados por crimes hediondos e equiparados, sob pena de esvaziar-se o tratamento rígido que a Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política criminal voltada a dirimir a traficância de entorpecentes, que, a propósito, envolve sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto devastam o país.

Não se olvida que a Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, permitindo ao (à) Juiz(íza) o desconto, na sentença, do tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta. Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado no caso em tela.

Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deva ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em razão do quantum, mas pelas graves circunstâncias e consequências do crime e reincidência do agente, que tornaram mais reprovável a conduta criminosa, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal. Há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa.

Acerca do assunto, outrossim, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração:

"É inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Deve o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria" (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 - Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015,

v.u.).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão no Juízo da Execução.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o acusado PAULO HENRIQUE DIAS DA SILVA, qualificado às págs.20/21, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelas razões expostas alhures.

O réu respondeu ao processo preso (convertida a prisão em flagrante em preventiva - págs.45/48).

Em que pese a excepcionalidade da custódia cautelar, a medida ainda é necessária para o atendimento da finalidade da persecução penal.

Presente o fumus comissi delicti, consubstanciado nas declarações dos policiais civis e na presente condenação. O periculum libertatis evidencia-se não apenas pela gravidade CONCRETA da conduta imputada ao acusado, diante das circunstâncias e consequências do delito acima apontadas, mas pelas desfavoráveis condições subjetivas, pois PAULO HENRIQUE dedica-se à prática ininterrupta de crimes e é reincidente.

Não se trata de presunção genérica de periculosidade de indivíduo assim acusado.

Cuida-se de constatação cotidiana, reforçada pelo legislador pátrio: O tráfico de drogas é atividade que denota a criminalidade organizada; a disseminação das drogas impõe aos usuários a prática de delitos antecedentes, contra o patrimônio alheio, para sua aquisição, e de delitos posteriores, geralmente contra pessoas, em razão da alteração do estado psíquico decorrente de seu consumo.

O acusado ostenta condenação anterior e irrecorrível por roubo majorado. É reincidente. Ainda cumpria a pena anterior quando se evadiu e, procurado pela Justiça, voltou a delinquir. Não há dúvida de que adota a prática de delitos como meio de vida. Há fortes indícios de que, em liberdade, voltará a delinquir. Não se cuida, na espécie, de apenas um desvio na vida do réu, que assim ostenta periculosidade acentuada e diferenciada, bem como conduta social avessa aos preceitos que presidem a convivência em comunidade.

As medidas cautelares previstas na legislação processual penal não se mostram, portanto, adequadas e suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo imprescindível para eficácia da persecução penal a manutenção da custódia cautelar. Não teriam idêntico efeito da prisão preventiva.

Quanto ao uso de algemas no acusado, na data do fato, com acerto observou a defesa que o procedimento só é lícito em casos de resistência ou de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros.

Os policiais civis afirmaram que o réu foi algemado por razões de segurança, diante da suspeita movimentação de pessoas na rua a partir da prisão do agente. A precaução era mesmo necessária, pois a quantidade de droga apreendida em poder do agente traz contornos de participação de Paulo Henrique em criminalidade mais organizada.

De qualquer forma, na hipótese dos autos a questão é secundária porque, juntamente com a prisão em flagrante do acusado, os policiais efetuaram a sua captura (pendente cumprimento de mandado de prisão, cf.págs.22/24). Com efeito, desde o momento da abordagem se verificou a veracidade da denúncia anônima quando à

situação do réu, procurado pela Justiça, que havia se evadido de estabelecimento prisional onde cumpria pena anterior e definitiva por roubo, após progressão para o regime semiaberto (autos DEECRIM nº 00095558-77.2017, cf. certidão criminal às págs, 29/31).

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o réu não poderá apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomende-se o acusado na prisão onde se encontra recolhido.

Em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ. Inexiste prejuízo aos sentenciados quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019) e não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar nesta sentença, há inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019).

Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Decreto em favor da União o perdimento dos aparelhos celulares e das malas apreendidas nos autos, usados para a prática do delito.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

De plano, não impugnados os laudos periciais:

a) e não tendo havido controvérsia sobre a natureza ou quantidade da substância ou do produto, bem como sobre a regularidade do respectivo laudo químico-toxicológico, oficie-se à Autoridade Policial para destruição das substâncias entorpecentes apreendidas nos autos;

b) autorizo a destruição das malas apreendidas e das folhas contendo as anotações contábeis depositadas em Cartório. Oficie-se à autoridade competente.

Oportunamente, comunique-se Distribuidor e IIRGD.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se guia de recolhimento definitiva;

b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;

c) Calcule-se a multa, intimando-se, em seguida, o acusado para que proceda ao pagamento;

d) Oficie-se à Autoridade Policial para destruição dos aparelhos celulares apreendidos nos autos.

Custas pelo réu no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA